



Poder Judicial de la Nación

PROTOCOLIZADO
T102 Ac.6/14 Mat. Penal
FCB 021434/2022/TO1

Córdoba, 18 de marzo de 2023.

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: “**LUCHESSOLI, JOSÉ ADRIÁN S/ INFRACCIÓN LEY 23737**” (FCB 21434/2022/TO1)”, llegados a despacho a fin de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I) Que el imputado José Adrián Luchessoli, representado técnicamente en estos obrados por los Dres. Ignacio Osta y Rolbi Oscar Valdivieso, solicitó la suspensión de juicio a prueba, en los términos del art. 76 bis del Código Penal.

A tal efecto, entre otra doctrina y jurisprudencia que entendió atinente al caso, invocó el precedente judicial “Acosta” de la CSJN para sustentar la procedencia del instituto aun cuando, por la escala penal de los delitos que se le imputan al nombrado, no resultaría aplicable una condena condicional. Ello, en la medida que privilegió para la interpretación de la norma penal los principios jurídicos de ultima ratio y pro homine.

Vale decir que, en un escrito posterior, el interesado amplió los fundamentos dados a los efectos de reforzar su petición de suspensión del juicio a prueba y mencionó que los hechos reprochados en este proceso ameritaban, en todo caso, su juzgamiento en la órbita provincial, habida cuenta el escaso hallazgo de pantas de marihuana y la discusión suscitada acerca de la comercialización de aceite de cannabis.

En este marco, introdujo un pedido de inconstitucionalidad de la escala penal del art. 5 de la ley 23.737, suponiendo que la sanción penal en abstracto que correspondería a los hechos reprochados al imputado, tendría un mínimo legal de tres años de prisión.

Por lo demás, en el escrito por el que se instó la presente resolución, ratificado luego en ocasión de la celebración de la audiencia oral, propuso en concepto de reparación del daño la suma de cien mil pesos (\$100.000), pagaderos



en cinco cuotas iguales, mensuales y consecutivas para ser destinado a una sociedad de beneficencia o entidad religiosa que el Tribunal designe.

Por último, considerando sus condiciones personales, ofreció cumplir trabajos no remunerados en una institución pública sin fines de lucro que designe el Tribunal o en la sugerida “Ciudad de los Niños”, ubicada en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

II) Que en ocasión de celebrarse la audiencia prevista en el art. 293 del Código Procesal Penal de la Nación, el Dr. Oscar Valdivieso ratificó el pedido de suspensión del proceso a prueba en favor de su asistido, reiterando los argumentos esbozados en los escritos presentados en formato digital.

A su turno, el auxiliar fiscal Dr. Augusto Richter, dictaminó en contra de la procedencia del instituto, básicamente porque los delitos y los hechos atribuidos a Luchessoli no permiten una eventual condena en suspenso en los términos del art. 26 del Código Penal, toda vez que la pena hipotética excedería el tope de tres años.

En este sentido, fundamentó que uno de los requisitos legales que habilitan la admisibilidad de este criterio de oportunidad reglado, como excepción al principio de legalidad, precisamente tiene que ver con la escala penal establecida en abstracto por la ley penal. Así, ratificó la consolidada doctrina judicial amplia de la CSJN, en sus fallos “Acosta” (331:858) y “Norverto” (N.326XLV), en cuanto al alcance que debe dársele al art. 76 bis del CP para la procedencia de la probation.

En esos términos, aclaró que solo es posible suspender la acción penal en aquellos procesos que involucren delitos o concurso de delitos que, por las circunstancias del caso, permitan dejar en suspenso la eventual condena. En virtud de lo prescripto por el art. 26 del CP, la imposición de una pena en forma de ejecución condicional, se supedita al delincuente primario cuya imputación refiera a un ilícito cuya sanción penal no exceda de tres años de prisión.

En el caso que nos convoca, los delitos que se le atribuyen a Luchessoli, principalmente en lo que hace a los tres primeros hechos, tienen una escala penal en abstracto de 4 a 15 años de prisión.

Por lo demás y en razón de los planteos efectuados por el defensor del imputado, el auxiliar fiscal recalcó la necesidad de la realización del debate o un





Poder Judicial de la Nación

análisis profundo del expediente y de las pruebas para determinar si es posible confirmar o desvirtuar la hipótesis delictiva achacada o eventualmente un cambio de calificación jurídica.

En definitiva, mencionó que esta no era la instancia para dilucidar esas cuestiones y por los mismos argumentos, desestimó el pedido de inconstitucionalidad propuesto por la defensa de Luchessoli.

Por lo cual, el Ministerio Público Fiscal se pronunció por el rechazo a la concesión de la probation al imputado.

III) Entrando al análisis de procedencia de la suspensión de proceso a prueba solicitada en favor de José Adrián Luchessoli, cabe señalar, en primer término, que conforme surge del requerimiento de elevación de la causa a juicio, se le atribuye la comisión de los delitos de siembra y cultivo de plantas destinadas a producir o fabricar estupefacientes -hecho 1-, guarda de semillas para producir o fabricar estupefacientes -hecho 2-, producción, fabricación, extracción o preparación estupefacientes, comercialización con plantas y semillas -hecho 3- (art. 5 inc. a b y c de la ley 23.737) y ejercicio ilegal de la medicina, sin autorización -hecho 4- (art 208 del Código Penal), en carácter de autor (art. 45 del Código Penal).

Todo ello, en función de la plataforma fáctica descrita en la acusación y que se transcribe a continuación: "HECHO 1: Desde abril de 2022 al 12 de septiembre del 2022, en el domicilio de calle Caseros N° 141/145 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, José Adrián Luchessoli sembró y cultivó veintiséis plantas de cannabis sativa de diferentes tamaños distribuidas en macetas: (doce plantines en el sector del lavadero, dos plantines en el depósito interno y 12 plantines más en el patio interno de la vivienda), todas estaban destinadas a producir y fabricar estupefacientes, más precisamente "Aceite de Cannabis". - Circunstancias acreditadas el día fecha 12 de septiembre de 2022 cuando el Subálferez Gonzalo Emmanuel Murray de la Unidad Especial de Investigaciones Santa Catalina de Gendarmería Nacional encabezó el allanamiento de esa vivienda, ordenado por el Juzgado Federal de Río Cuarto. - HECHO 2: Desde abril de 2022 al 12/09/2022, en el domicilio de calle Caseros N° 141/145 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba José Adrián Luchessoli, guardó 585 unidades de semillas de marihuana y



76 gramos de cannabis sativa elementos destinados a producir y fabricar estupefacientes, más precisamente “Aceite de Cannabis”. Conforme el Informe Pericial N° 109397, las semillas secuestradas poseen el 80% de viabilidad germinativa y el material vegetal se trata de marihuana con un peso de 76 gramos que tendría 1071,6 microgramos de THC que equivalen a 306.17 dosis umbrales.- Circunstancias acreditadas el día fecha 12 de septiembre de 2022 cuando el Subálferez Gonzalo Emmanuel Murray de la Unidad Especial de Investigaciones Santa Catalina de Gendarmería Nacional encabezó el allanamiento de esa vivienda, ordenado por el Juzgado Federal de Río Cuarto e incautó 585 semillas en el sector del lavadero.- HECHO 3: Desde abril de 2022 al 12/09/2022, en el domicilio de calle Caseros N° 141/145 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, José Adrián Luchessoli fabricó, preparó y produjo “Aceite de Cannabis” para su posterior comercialización, secuestrándose en su “laboratorio”, a saber: Ciento treinta (130) frascos de 30 ml; Cinco (5) frascos de 710 ml.;- Cincuenta y nueve (59) frascos de 10 ml;- Tres (3) frascos de distinta capacidad; Veinticinco (25) frascos de 20 ml y Tres (3) frascos de 3 litros de Aceite de Cannabis, los que se encontraban distribuidos en diferentes sectores del inmueble (living, lavadero, garaje), en los que se detectó la presencia del principio activo Delta 9 Tetrahidrocannabinol (THC), conforme pericia N° 109.397 . Así el día el 11 de agosto de 2022, en calle Caseros N° 141 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, José Adrián Luchessoli, vendió dos frascos de aceite de cannabis y un frasco de hojas de coca por la suma de \$12.000, dicha compra fue efectuada por el Agente Revelador -designado por resolución del 09/08/2022-(Cfme. Pericia N° 107546).- Además, en fecha que no ha podido precisarse, pero anterior al 17 de mayo de 2022, José Adrián Luchessoli comercializó “aceite de cannabis sativa” a una mujer embarazada -según surge de las transcripciones telefónicas contenidas en el CD 54.- HECHO 4: Desde abril de 2022 al 12/09/2022 -fecha de los allanamientos-, de manera telefónica a través de su abonado 358- 5622140 y/o personalmente en su domicilio de calle Caseros N° 141/145 de la ciudad de Río Cuarto, José Adrián Luchessoli, prescribió y administró, de manera habitual “Aceite de Cannabis”, a diferentes personas, sin contar con título habilitante ni autorización para el ejercicio del arte de curar, ello so pretexto de un





Poder Judicial de la Nación

tratamiento de patologías que padecían y por lo cual recibía consultas de diferentes personas. Así, el día 11 de agosto de 2022, en su domicilio de calle Caseros N° 141 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba José Adrián Luchessoli, prescribió al agente Revelador “Aceite de Cannabis”, vendiéndole por la suma de \$ 12.000, dos frascos de aceite de cannabis y un frasco de hojas de coca.”

Hecha una reseña de los hechos efectuadas en la instrucción, en lo que se sigue, se efectúan las consideraciones que corresponden a esta instancia.

Vale decir que es conocida la doctrina judicial sentada por la CSJN a través del pronunciamiento dictado en autos “ACOSTA, Alejandro Esteban S/Infracción art. 14, 1er Párrafo Ley 23.737”, en cuanto interpretó ampliamente los supuestos de aplicación contemplados en el art. 76 bis del Código Penal.

De allí que, dentro del universo de casos que en sus propiedades relevantes habilitan la suspensión de juicio a prueba, se encuentran, por un lado, aquellos delitos de acción pública reprimidos con pena de prisión cuyo máximo no supere los tres años (primer y segundo párrafo), y por el otro, los delitos previstos en la ley penal con una sanción superior a ese tope (cuarto párrafo), pero que, por las circunstancias del caso, se permitiría el dictado de una condena en suspenso de conformidad al art. 26 del Código Penal.

En este último supuesto, se encuadraría el caso bajo análisis, dado que la pena mínima establecida para los delitos incluidos en el art. 5 de la ley de drogas supera el máximo legal de tres años de prisión establecido como presupuesto de condena condicional.

A su vez, para este grupo de delitos, la norma adiciona especialmente la necesidad del consentimiento fiscal. Es decir que, para la concesión del instituto bajo análisis, la ley exige además de la posibilidad de condena condicional si las circunstancias del hecho lo ameritan, el dictamen favorable del titular de la acción penal.

Al respecto se adelantó que el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la procedencia de la suspensión de juicio a prueba. En su exposición, brindo suficientemente las razones en orden a sustentar la imposibilidad de subsumir el caso en las condiciones requeridas para el otorgamiento de la probation.



Dicho esto, a mi criterio, el dictamen esbozado por el auxiliar Fiscal goza del carácter de logicidad y fundamentación requerido a los fines de su recibo, toda vez que, sin que signifique adelanto de opinión al respecto, aparecen razonableS los motivos allí expuestos para oponerse a la suspensión de juicio a prueba.

Es decir, se trata de una conclusión del Fiscal que aparece fundada, razón por la cual se torna operativo lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en el Acuerdo N° 1/99 en Plenario N° 5, “Kosuta, Teresa R. s/ recurso de casación” emitido el 17/8/1999. En tanto y en cuanto, en este aspecto la doctrina judicial continúa vigente.

En el punto respectivo de la sentencia plenaria aludida, que aparece obligatoria para este Tribunal (art. 10 de la ley 24.050), se estableció que “(...) el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional y, en particular, que esa facultad privativa se encuentra expresamente prevista no sólo en la ley y en el Código Procesal Penal de la Nación (artículos 65 y cc.), sino también en la Ley Orgánica del Ministerio Público (...) cuando señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público (Título II, Sección I, artículo 25): ‘a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad;(...) b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera; (...) c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales(...)’.-

A su vez, sostuvo la citada Cámara, siguiendo este orden de ideas, que cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal, el tribunal, carente de facultades autónomas para su promoción y ejercicio, tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio.

Entonces, el consentimiento del fiscal implica su aquiescencia, y por tanto, no podrá disponerse la suspensión de juicio a prueba sin previo dictamen fiscal





Poder Judicial de la Nación

concordante. Luego, su negativa debe ser debidamente fundada y corresponde al juez controlar la razonabilidad y logicidad de dichos argumentos.

Debo decir, entonces, que ambos extremos han sido satisfechos en los argumentos del Ministerio Público Fiscal, de manera suficiente, concluyente y correcta desde el punto de vista lógico como sustancial. De allí que resulta vinculante para este tribunal.

Por último, y en consonancia con lo argumentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, no corresponde ingresar al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de la escala penal establecida en abstracto por el art. 5 de la ley 23.737.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es conteste en afirmar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal “es un acto de suma gravedad y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y que por ello debe considerarse como la última ratio del orden jurídico y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, o bien cuando se trata de una objeción constitucional palmaria, de tal forma que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera” (cfr. CSJN, Fallos: 258:60; 292:211; 296:22, entre otros).

Así, el máximo Tribunal del país ha señalado que la inconstitucionalidad sólo puede operar cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que forman parte de ella (CSJN, Fallos: 285:322; 288:325; 290:226).

De tal modo, el carácter excepcional de la declaración de inconstitucionalidad de una norma obliga a efectuar una valoración precisa de las circunstancias del caso, a los efectos de establecer si concurren extremos de gravedad institucional que la justifiquen, por constatación —en definitiva— de una contradicción manifiesta de una ley con la cláusula constitucional.

Entonces, la necesidad de evaluar, en el caso concreto la eventual violación de la Constitución Nacional, supone un examen detenido de las pruebas arrimadas al proceso y otras circunstancias, que no ocurre en esta instancia.



En función de lo expuesto,

SE RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR a la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de José Adrián Luchessoli, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos.

Protocolícese y hágase saber.-

**JULIAN FALCUCCI
JUEZ DE CAMARA**

**HERNAN MOYANO CENTENO
SECRETARIO DE CAMARA**

Seguidamente, se notificó electrónicamente la resolución que antecede al Sr. fiscal general, Dr. Casas Noblega, auxiliar fiscal, Dr. Richter, y a los Dres. Osta y Valdivieso. Conste.-

**HERNAN MOYANO CENTENO
SECRETARIO DE CAMARA**

